

1500358-91.2019.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Tiago pela prática de crime de mesma espécie: tráfico de entorpecentes (fls. 203/204). Ademais, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tendo em vista que o crime foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional.

Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provadas a autoria e materialidade, e afastadas as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500358-91.2019.8.26.0593 - lauda

CONCLUSÃO

Em 01 de agosto de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Anelisa Rodrigues Sastre, M369921, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500358-91.2019.8.26.0593 - Controle 2019/002695

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

STEFANY CAROLINE SENACHI e outro

Vistos.

STEFANY CAROLINE SENACHI (RG: 45.384.717, filha de Janaína Letícia Senachi) e TIAGO VITAL FOIZER (RG: 59.025.934, filho de Lourival Foizer e Cláudia Aparecida Vital Foizer) foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, c. c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, atendidas as disposições do artigo 29 do Código Penal e da Lei n. 8.072/90 (crime equiparado a hediondo), porque, Stefany Senachi, no dia 27 de outubro de 2019, por volta das 10h, na Penitenciária de Marília-SP, situada na Rodovia SP 294, km 465, neste município e Comarca de Marília/SP, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 1 (um) invólucro plástico contendo 55,39g (massa líquida) de Cannabis sativa L, vegetal conhecido por maconha, que possui tetrahydrocannabinol, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica. Tiago, por sua vez, que estava preso no referido estabelecimento, concorreu, de qualquer modo, mediante induzimento e instigação, para a conduta da corré Stefany.

Recebida a denúncia em 29 de novembro de 2019 (fls. 71/72), os réus foram citados (réu Tiago - fls. 94 - ré Stefany - fls. 112) e apresentaram resposta à acusação

(fls. 121/123).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, sendo, os acusados, interrogados ao final.

Alegações ministeriais nos termos de audiência às fls. 221/225 e alegações defensivas às fls. 228/243.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3), boletim de ocorrência (fls. 8/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação (fls. 19/21), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 49/51) e pela prova oral colhida. A autoria quanto aos réus é certa e repousa sobre os acusados.

A testemunha, João Carlos Straiotto, agente penitenciário, ouvido na fase inquisitiva (fls. 4), declarou que, na data dos fatos, estava trabalhando, na área do aparelho de scanner, quando a acusada Stefany, a qual foi até a penitenciária visitar seu companheiro, corréu Tiago, ao passar pelo scanner foi flagrada portando entorpecente em sua genitália. Contou que o aparelho acusou uma imagem diferente no corpo da acusada, que foi questionada se portava algo, e ela afirmou que sim, sendo encaminhada para um local reservado na presença das agentes penitenciárias Tania Maria e Sheila para retirar o objeto. Em seguida, a ré Stefany retirou um invólucro plástico de seu órgão genital, o qual continha em seu interior uma porção de erva esverdeada semelhante a maconha. Em juízo, ratificou a versão já prestada na fase inquisitiva. Contou que não se recorda com clareza das palavras da ré, mas se lembra dela ter dito que a droga não seria para o réu Tiago e sim para uma outra pessoa que a procuraria dentro do estabelecimento, sem entrar em detalhes de quem seria essa pessoa. Quanto ao réu, nada sabe dizer, pois não tiveram contato, mas afirmou que a visita da ré Stefany seria para o seu companheiro, corréu Tiago.

A testemunha, Tania Maria Zafra Kawamoto, também agente penitenciária, ouvida em solo policial (fls. 5), confirmou a descrição dos fatos realizada pela testemunha João Straiotto, sendo ela quem presenciou a ré retirar um invólucro plástico de seu órgão genital, o qual continha em seu interior uma porção de erva esverdeada semelhante a maconha. Em juízo, confirmou a versão anteriormente prestada e disse que a ré informou que a droga seria destinada a uma pessoa que a procuraria dentro do estabelecimento prisional. Indagada, afirmou que, pelo histórico de visitas da penitenciária, na ocasião dos fatos, era a segunda ou terceira visita da ré ao seu companheiro, o corréu Tiago.

A testemunha arrolada pela defesa Lindomar Bruno de Oliveira, ouvida apenas em juízo, disse que conhece a ré Stefany, pois realizavam visitas na mesma penitenciária. Contou que não presenciou os fatos, soube apenas pela própria acusada que ela fora abordada na pista e pediram para levar a encomenda e ela aceitou.

A acusada, Stefany Caroline Senachi, na Delegacia (fls. 6), afirmou que seu marido estava preso na penitenciária de Marília e que foi coagida a levar a droga para dentro do presídio. Contou que recebeu um telefonema, dias antes dos fatos, em que uma pessoa desconhecida lhe disse que deixaria a droga em determinado lugar para que ela pudesse pegar e entrar com o entorpecente no presídio, caso contrário matariam o seu marido, o corréu Tiago. Em juízo, ratificou integralmente a versão prestada na Delegacia.

Na fase inquisitiva (fls. 52), o acusado, Tiago Vital Foizer declarou que pediu, em uma visita anterior, para a sua companheira, corré Stefany, trazer maconha no dia de visita e, de imediato, ela negou. Entretanto, em razão da sua insistência, convenceu sua companheira a atender seu pedido, ensinando-a como deveria proceder. Afirmou que estava desesperado pela droga, pois estava sendo ameaçado, e o entorpecente serviria para pagar uma dívida contraída no interior da prisão, relacionada ao uso de drogas. No dia da visita, foi informado que Stefany fora flagrada pelo sistema de segurança durante a revista. Em juízo, negou que tivesse pedido à corré para lhe levar drogas no dia da visita, sendo que o depoimento prestado na fase inquisitiva nesse sentido foi uma sugestão de um guarda da penitenciária com o único objetivo de que a corré não permanecesse presa.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelos acusados.

Primeiro, oportuno advertir que os agentes penitenciários são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbram elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoas inocentes, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e “plantando” provas.

Neste sentido: "Nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais civis tivessem motivos para incriminar falsamente o sentenciado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos. Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998)

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)" (TJSP, Apelação Criminal n. 1528155-70.2019.8.26.0228, Rel. Des. Otávio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.21).

Ainda, por analogia: "Anotar-se que a atuação dos agentes públicos se revestiu de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. O juiz não pode olvidar que, hodiernamente, os civis se recusam a depor por medo de represália (moram no mesmo reduto do tráfico, na mesma rua do suposto traficante preso etc.), de modo que o testemunho policial sempre se sobressai, merecendo o valor correspondente à realidade aferida. Não existe dispositivo legal que vede ao agente da lei servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, os funcionários públicos têm a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente." (TJSP, Apelação Criminal nº 1501636-73.2019.8.26.0126, Des. Jayme Walmer de Freitas, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.2021).

Esse também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Nesse particular, registre-se que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando

corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, bem como as reiteradas informações anônimas sobre a traficância que foram confirmadas pelos agentes públicos, como ocorreu no presente caso. Ademais, a condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). Nestes termos, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso." (STJ, Habeas Corpus nº 633.615 SP, Min. Félix Fischer, Decisão Monocrática, j. 27.1.2021).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos agentes penitenciários foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, confirmando-se na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar os réus.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que os acusados praticaram condutas descritas nos artigos 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei de Drogas, ou seja, Stefany Senachi realizou a conduta de trazer consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas sem autorização legal e regulamentar nas dependências de estabelecimento prisional. Tiago, por sua vez, nos termos do artigo 29 do Código Penal, concorreu para os crimes e, portanto, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Do exame dos autos, extrai-se que os agentes penitenciários flagraram Stefany trazendo consigo droga ilícita, como consta no laudo de constatação (fls. 19/21) - ratificado por laudo de exame químico-toxicológico (fls. 49/51). Dado o objetivo da ré de ocultar a droga em sua genitália, somente com o auxílio de equipamento de segurança e monitoramento da penitenciária foi possível identificar tal conduta típica. O acusado Tiago, por sua vez, foi quem pediu para a corré, sua companheira à época, levar os entorpecentes para dentro do estabelecimento prisional, o que, inclusive, confessou, em seu depoimento na Delegacia, dizendo que a ensinou como proceder.

Destaca-se que, muito embora haja a negativa do acusado Tiago em juízo quanto à prática do crime, ela restou isolada das demais provas dos autos.

Da mesma forma, a versão da acusada de que seu companheiro foi ameaçado de morte, o que a motivou aceitar a proposta de uma pessoa desconhecida para adentrar à Penitenciária em posse da droga, encontra-se isolada das provas constantes nos autos, não sendo possível, assim, suscitar o instituto da coação moral irresistível. Afinal, poderia, a ré, procurar as autoridades competentes e contar, na primeira oportunidade, da ameaça que sofreu, o que não ocorreu no caso concreto. Preferiu ela arriscar-se a entrar com a droga no presídio e foi descoberta apenas porque, ali, há scanner.

Sobre o elemento subjetivo do tipo do artigo 33 da LD, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando à consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas.

Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'".

Neste contexto, observo que as circunstâncias da prisão da ré (com grande quantidade de droga quando entrava para visitar o marido no presídio), as condições em que se desenvolveram a ação (levar entorpecentes ocultos em seu corpo à penitenciária para o seu companheiro e a pedido dele), bem como os antecedentes de Tiago (condenado recentemente por tráfico ilícito de entorpecentes), revelam que se tratam, os acusados, de traficantes.

Por fim, no que se refere às alegações feitas pela defesa no sentido da atipicidade da conduta (pelo fato de os entorpecentes não terem sido efetivamente entregues) e

concernente ao fato de que o meio utilizado pela acusada seria absolutamente ineficaz, tratando-se, portanto, de crime impossível, cito pacificada jurisprudência em sentido diverso:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU CRIME IMPOSSÍVEL - NAO ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO COM O RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA ATENUANTE DA CONASSAO ESPONTANEA EM FAVOR DO REU DIEGO I - Impossível a decretação da absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas se os elementos probatórios reunidos durante todo o iter processual demonstram satisfatoriamente que os réus somaram esforços visando introdução de uma porção de maconha em unidade prisional. O firme relato apresentado pelos policiais, devidamente secundado pelas confissões extrajudiciais e evidências que decorrem do flagrante, são todos elementos capazes de comprovar, além de qualquer dúvida razoável, o fato criminoso narrado na denúncia. II – O crime impossível, previsto no art. 17 do CP, demanda a constatação acerca do irremediável prejuízo à consumação do delito em razão da ineficácia absoluta do meio empregado ou da absoluta impropriedade do objeto. Na hipótese vertente, o meio empregado pelos réus não seria suficiente para impossibilitar consumação do crime de tráfico de drogas, pois a submissão de visitantes a aparelhas eletrônicos ou à revista íntima não são capazes de inibir, com absoluta certeza, o ingresso de drogas em unidades prisionais. Ademais, a consumação do delito ocorreu no momento em que ré trouxe consigo a substância entorpecente, sendo irrelevante a ausência de tradição da substância entorpecente ao réu recolhido no estabelecimento penitenciário. Logo, não há falar em absolvição pela alegada impossibilidade de consumação do crime. (...) IV – Recurso improvido com o reconhecimento ex officio da atenuante da confissão espontânea em favor do réu Diego. (...) (TJMS. Apelação Criminal n. 0000540-56.2019.8.12.0007, Cassilândia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Emerson Cafure, j: 06/01/2020, p: 08/01/2020)

Quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois a quantidade de drogas encontrada com os acusados e as circunstâncias do crime demonstram o anterior envolvimento dos réus com o mundo do crime, principalmente levando em consideração recente condenação, já em segundo grau, do corréu Tiago pela prática de crime de mesma espécie: tráfico de entorpecentes (fls. 203/204). Ademais, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tendo em vista que o crime foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional. Portanto, caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, provadas a autoria e materialidade, e afastadas as teses defensivas por tudo que se expôs passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Ré Stefany

Artigo 33, caput, na forma do artigo 40, inciso III, ambos da LD

Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, fixo a pena em seu mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes as agravantes e atenuantes, mantenho a pena no patamar mínimo: 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, majoro a pena em 1/6 (um sexto) em razão do artigo 40, inciso III, da LD, tornando definitiva a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é imposta em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Réu Tiago

Artigo 33, caput, na forma do artigo 40, inciso III, ambos da LD c.c. Artigo 29, caput, CP

Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal e em da condenação recente por crime idêntico, o que demonstra personalidade

voltada à prática criminosa, aumento a pena base em 1/6 (um sexto): 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, não vislumbro a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase de aplicação da pena, ausentes causas de diminuição de pena, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto) em razão da incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da LD, tornando definitiva a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada qual no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Fixo o regime inicial semiaberto como inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade estabelecidas, ante o quantum imposto, na forma do artigo 533 do Código Penal.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar STEFANY CAROLINE SENACHI, qualificada nos autos, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três), fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e TIAGO VITAL FOIZER, qualificado nos autos, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no 33, caput, c.c. Artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em respeito ao § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, diante da ausência de circunstâncias cautelares concretas e tendo em vista que responderam ao processo em liberdade, concedo aos acusados o direito de recorrer da presente decisão da mesma forma.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Oportunamente, expeça o necessário para a execução das penas impostas. Oficie-se ao TRE para cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Expeçam-se os demais ofícios e as comunicações de praxe.

P.I.C.

Marília, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA